

1500953-07.2021.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... ser conhecido dos meios policiais pelo narcotráfico, incluindo ser membro de organização criminosa notoriamente conhecida por explorar o tráfico de drogas, tanto que anteriormente condenado pelo narcotráfico (cf. fls. 51). Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500953-07.2021.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500953-07.2021.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO CRISTIANO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. TIAGO CRISTIANO DOS SANTOS, qualificado a fls. 18, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de

novembro de 2021, por volta das 5h, na Rua 25-B nº 1.455, Centro, nesta cidade e Comarca, teria em depósito, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, dezessete porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 11,900 g, além de uma porção de maconha, com peso líquido de aproximados 75,300 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que “o denunciado tinha em sua residência, para fins de tráfico, as drogas acima descritas, as quais mantinha em depósito debaixo do colchão e no interior do tanque de lavar roupas.

Policiais militares receberam a informação de que uma mulher estava sofrendo violência por parte do marido, razão pela qual se deslocaram ao imóvel indicado e se depararam com a ofendida encolhida no canto da parede, sobre a cama, protegendo as crianças.

Os agentes, então, realizaram buscas pela residência, ocasião em que encontraram 17 (dezessete) eppendorfs contendo cocaína debaixo do colchão, além de, no interior do tanque de lavar roupas, uma porção de maconha.

Com efeito, a dinâmica dos fatos, a natureza e a quantidade dos entorpecentes encontrados e o local onde estavam escondidos demonstram que as drogas pertenciam ao denunciado e que se destinavam ao comércio espúrio.

O delito foi cometido em época de calamidade pública ocasionada pela COVID-19, em situação em que as vítimas estão indubitavelmente mais vulneráveis diante da necessidade de se realizar o distanciamento social.”.

A denúncia de fls. 102/104 foi recebida em 16 de dezembro de 2021 (fls. 105), sendo o Réu citado (fls. 112), apresentando defesa preliminar em fls. 122/123, rejeitada em fls. 125/126. Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 171/184).

Em memoriais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 153/154).

A douta Defesa, por seu turno, arguiu preliminar e no mérito requereu a improcedência da ação, alegando a inexistência de provas que indicassem ser o Réu narcotraficante, daí porque deveria ser absolvido. Subsidiariamente pediu a desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06 e, de qualquer forma, a fixação da pena no piso, com regime aberto para cumprimento, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 155/170).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A preliminar arguida em alegações finais defensivas se liga ao mérito e ali será enfrentada.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/07), boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação de fls. 15/17, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 117/119, além da prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria é certa contra o Réu que, na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 07), ao passo que em Juízo negou o teor da denúncia, sustentando, a fls. 180/184, que houve uma denúncia de agressão contra sua esposa, mas na verdade teria chegado em casa drogado e como pretendia voltar para rua foi por ela impedido, sendo que quando os policiais chegaram encontraram as crianças chorando e, por isso, lhe deram voz de prisão, passando a conversar com sua mulher, assim como lhe indagaram se havia droga, instante em que ele confirmou a existência da maconha que estava no

tanquinho, dentro de uma bermuda, motivo pelo qual permaneceram em sua residência até amanhecer, para vasculhar o quarto, que estava com a lâmpada queimada. Foi conduzido à delegacia e lá se negou a assinar qualquer documento, negando que a cocaína estivesse em sua residência. Ademais, tem ocupação lícita, não autorizou o ingresso dos policiais na casa e é usuário de drogas.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que o Réu nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois ele “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

Sua versão não se sustenta.

A companheira do Acusado, Rafaela, prestou depoimentos contraditórios, porquanto, quando da prisão em flagrante, ela foi enfática ao relatar que estavam amasiados há um mês e por desentendimento entre eles provavelmente algum vizinho acionou a polícia, declarando que ele “é usuário de drogas e também trafica desde que saiu da cadeia” (cf. fls. 06). Em Juízo, em um depoimento nada convincente, ela tentou alterar essa versão, dizendo que o companheiro tinha consumido entorpecente a noite toda e chegado em casa drogado, queria sair novamente e foi impedido, ficando alterando, tendo os vizinhos acionado a polícia, que no local encontrou maconha no telhado, mas não havia cocaína. Ademais, disse que estava nervosa na delegacia e eles queriam que ela registrasse ocorrência contra o Acusado, não se recordando de ter dito que ele era traficante (fls. 171/173).

O policial militar José Roberto declarou, em fls. 174/176, que foram acionados a comparecer ao local porque um rapaz estaria agredindo a esposa e as crianças, encontrando o portão aberto, confirmando a discussão, com a esposa acusada na cama e como o Réu é conhecido dos meios policiais pelo tráfico vasculharam a casa encontrando entorpecente debaixo do colchão e no tanquinho, tendo o Acusado confirmado a propriedade, mas não disse para qual finalidade serviria. No mesmo sentido o depoimento do policial Almeiani, que em fls. 177/179 ainda disse que o Réu é conhecido dos meios policiais, sendo membro do PCC, comandando aquele bairro.

Pois bem.

A versão dada pela companheira do Réu em Juízo merece pouco crédito, porque deu mostra clara do temor que sentia, desdizendo aquilo que espontaneamente foi colhido no calor dos fatos, não podendo se ignorar que estavam juntos há pouco tempo e, segundo informações trazidas pelo policial militar acima mencionado, ele seria um dos líderes de facção criminosa responsável por aquele bairro.

Não bastasse, a isolada alegação do Réu não merece acolhida, porque não é se de se supor que estivesse mesmo na rua e para lá pretendia retornar para conseguir mais droga (cf. fls. 182), deixaria aquela considerável quantidade de maconha – que ele admite era sua – em sua residência, já que estava apta ao consumo.

A conduta do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local apontados na denúncia, tinha em depósito substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a quantidade e diversidade de maconha e cocaína apreendidas, o local em que localizada, a declaração de sua companheira confirmando a traficância, o fato de ser conhecido dos meios policiais pelo narcotráfico, incluindo ser membro de organização criminosa notoriamente conhecida por explorar o tráfico de drogas, tanto que anteriormente

condenado pelo narcotráfico (cf. fls. 51). Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

O teor da prova colhida dá conta da participação do Acusado na traficância, sendo que a negativa é frágil e completamente rechaçada pelo uníssono depoimento dos policiais militares, que já tinham informação sobre o Réu na prática deste crime, corroborando a declaração prestada pela sua companheira no momento de sua prisão, que foi negada em Juízo malgrado sem que houvesse qualquer esclarecimento para a alteração de sua fala inicial.

Lado outro, o simples fato de ser usuário - sequer comprovado -, não exclui a possibilidade da narcotraficância, sendo, no mais, condutas que comumente caminham juntas.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

A alegação de invasão de domicílio deve ser afastada, considerando que o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 10.343/06 é classificado como permanente, de modo que a consumação se arrasta no tempo e permite a prisão em flagrante a qualquer momento. Sendo assim, não era necessária autorização judicial para ingressar na residência em que se encontrava o Acusado, agindo os agentes policiais dentro da exceção à regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, insculpida no artigo 5º, inciso XI, da CF/88: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" (destaquei).

Ao contrário do que sustenta a douta Defesa não se constata a existência de irregularidade na atuação dos policiais porque havia justa causa, tendo se baseado os agentes públicos no fato de que havia prática de aparente violência doméstica, somente não apurada porque a vítima não ofereceu representação (cf. fls. 06), o que exigiu o ingresso dos policiais na casa e ali se constatou a existência de entorpecente, que, segundo depoimento do Réu, foi por ele apontando o local onde se encontrava a maconha (cf. fls. 181), não podendo se falar de ilegalidade da prisão. Nesse sentido: "inadmissível acenar com 'violação de domicílio', revestida de licitude a conduta dos policiais até porque se cuidava, no caso, de crime permanente, e diante do teor do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, nem era preciso que estivessem eles munidos de mandado judicial de busca, como já se decidiu nesta Corte de Justiça em casos assemelhados (Apel. nº 0000462-78.2014.8.26.0579, rel. Luis Soares de Mello, j. em 27.9.2016; Apel. nº 0001645-68.2014.8.26.0067, rel. Amaro Thomé, j. em 24.11.2016; Apel. nº 0001998-97.2014.8.26.0491, rel. Min. Edison Brandão, j. em 1.11.2016; Apel. nº 0000674-87.2007.8.26.0145, rel. Sérgio Ribas, j. em 31.3.2011). Reiterada aliás essa orientação (HC nº 352.811/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 28.6.2016), inclusive na c. Suprema Corte (RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 5.11.2015)" (TJSP, HC 0023205-68.2017.8.26.0000, 4ª C.D.Crim., Relª Desª Ivana David, j. 31.10.2017).

De igual forma: "recentemente, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616, o C. Supremo Tribunal Federal aprovou a tese, em repercussão geral, segundo a qual a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas posteriormente que indiquem que dentro da casa ocorre situação de

flagrante delito. Entendeu-se que, segundo o artigo 33 da Lei de Drogas, configura-se delito permanente guardar entorpecentes ou mantê-los em depósito e o artigo 303 do Código de Processo Penal considera como situação de flagrância aquele que estiver cometendo crime permanente" (TJSP, Revisão Criminal 0008744-28.2016.8.26.0000, 5º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 14.09.2017).

Deste modo, justificado o ingresso, a atuação policial foi de acordo com o entendimento firmado pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 603.616, representativo da controvérsia: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

Sobre o tema: "a ideia de abuso de autoridade em decorrência da invasão de domicílio, sem ordem judicial, na forma como sugerido pela combativa Defesa, não impede o prosseguimento da ação penal. A conduta imputada ao réu (guardar entorpecente) é crime de natureza permanente, cujo momento consumativo se protraí no tempo, autorizando a qualquer momento a ação policial. Não por outro motivo, recentíssima decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu como legítima a busca e apreensão sem mandado judicial em crime permanente (HC 127457). O relator do caso, ministro Dias Toffoli, lembrou em seu voto que diversos precedentes da Corte apontam no sentido de ser dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias. Nesse caso, não se pode falar em ilicitude das provas obtidas. Isso porque, no caso de crime permanente, explicou o ministro Celso de Mello ao acompanhar o relator, o momento consumativo do delito está sempre em execução. (<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293229> acesso em 11.06.2015).

Por ora, os elementos indiciários contidos no caderno policial sugerem que os milicianos agiram no estrito cumprimento do dever legal, posto que fundadas razões, em torno da possível prática delitiva, inclusive de ordem objetiva, justificaram o ingresso no imóvel apontado na denúncia, como forma de combate à criminalidade que ocorria.

Daí que, na forma como já advertido pela Suprema Corte, 'do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida. (...) Por estar a certeza fora do alcance, a legislação costuma exigir modelos probatórios bem mais modestos para medidas de investigação. Para busca e apreensão, por exemplo, o Código de Processo Penal exige apenas fundadas razões' (STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 05.11.2015)" (STJ, HC 435465, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.02.2018).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade. Sendo assim, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado é reincidente, demonstrando ter personalidade persistente na prática de condutas antissociais, sendo que na primeira fase da dosimetria, deixo de empregar como fundamento da majoração para evitar bis in idem com a agravante da reincidência. Não obstante, nesta fase inicial, aumento sua pena em ¼ (um quarto), devido à considerável quantidade de maconha e de cocaína apreendidas, evidenciando maior perniciosidade de sua conduta. Sendo assim, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, a pena-base é fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no menor valor à míngua de comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aumento-a em 1/3 (um terço) em razão da reincidência específica (cf. fls. 51, autos nº 0002566-49.2015.8.26.0210),

evidenciando persistência na prática deste crime equiparado ao hediondo, exigindo que sua reiteração seja objeto de maior repreensão, atingindo, então, o patamar de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, que a torno definitiva.

Por outro lado, rejeito a pretensão de majoração da pena com base no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não há qualquer indicação de que tenha o Réu se aproveitado da pandemia para praticar o crime de tráfico, não se verificando relação direta deste período de exceção com a prática do ilícito, não se podendo admitir interpretação extensiva a ponto de se exacerbar a condenação somente pelo momento em que praticado o delito, sob pena de se tornar padrão para todo e qualquer crime praticado durante o tempo em que grassar a peste. Nesse diapasão: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.
2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito.
3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente.
4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados" (STJ, HC 654.255/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.05.2021 - grifei).

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade

do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Crim., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência do requisito subjetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido

pelo traficante (ainda que seja um “pequeno” traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito (das quais o Réu não é possuidor de nenhuma) servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: “Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012).

E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita” (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda do telefone celular apreendido com o Réu, depositado em Juízo, que deverá ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu TIAGO CRISTIANO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em seu piso legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a concessão de sursis e a substituição por pena restritiva de direitos. No mais, decreto a perda do telefone celular apreendido com ele, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como encaminhe-se o numerário apreendido, depositado a fls. 38, em benefício da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo por que mantenho sua prisão cautelar sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada justificando que preso em flagrante fosse colocado em liberdade depois de condenado.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA